论 文 翻 译 ——Democratic Enforcement? Accountability and Independence for the Litigation State

Margaret H. Lemos, Democratic Enforcement? Accountability and Independence for the Litigation State, 102 CORNELL L. REV. 929, 935 (2017).

文章大纲：

引言
一、绘制问责制图谱：为何、对谁、以及为何事？
A. 政治问责制与代表制
B. 问责制与独立性的权衡
二、公共执法中的问责制与独立性
A. 支持问责制的理由
1. 作为自由裁量性政策制定的执法
2. 公共执法的希望与风险
B. 执法与独立性
1. 与裁决的类比
2. 公众舆论的尴尬角色
C. 作为政治代表的执法
三、实践中的执法问责制
A. 联邦执法：政治控制
1. 总统
2. 国会监督
B. 州执法：选举
C. 公众参与
四、监管私人影响
A. "阳光"下的执法
B. 规制执法者选举
C. 游说
结论

摘要

法律和政治理论文献中有大量内容关注民主政府中的问责制和独立

性问题。评论者倾向于**在立法和监管领域推崇问责制，在裁决背景下推崇独立性**。然而，他们很大程度上忽视了位于立法和法律适用交汇处的政府职能：**执法**。理论上的空白反映在我们当前的法律和制度结构中。当一个机构提出新法规时，我们有相应的规则来促进监管过程中的政治问责、公众参与和中性专业知识。然而，当同一机构采用新方法来执行相关法规和规章时，我们缺乏同等机制来使政府行动合法化。（行政机关制定的法规与执行方法是两个问题）

本文旨在填补这一空白。聚焦于民事/刑事分野的民事方面，我发展了一种执法理论，以理解其在我国政府体系中的地位。我解释道，执法在运作方式上连接了立法和裁决——将案件提交给裁决者，以便将普遍适用的法律解释并适用于特定个人和公司——也在它与那些更熟悉的治理模式所共有的特征上连接了两者。执法是一种自由裁量性政策制定的形式，需要与立法特征相同的政策判断，并引发对问责制、透明度和公众参与的类似要求。但执法者还必须做出我们通常与裁判相关的个性化、追溯性的法律决定，这使得最强烈的民众控制形式显得不合适。

借鉴民主理论，我认为问责制与独立性之间看似存在的紧张关系可以通过将执法理解为一种政治代表形式来解决。从这个角度看待执法有助于揭示问责制在执法背景下的重要性，同时也表明执法者可以"代表"公众，而无需盲从公众意愿。说公共执法应该问责，并不是要否认自主专业判断的必要性，而是要坚持政府有责任告知公民以其名义所做的事情，并反过来倾听他们的意见。呼吁问责也是呼吁建立机制，使公民可以尝试前瞻性地影响执法，或追溯性地"追究其责任"。对公众的问责意味着需要一定程度的隔离，免受狭隘私人利益的影响。

我们目前对执法的处理远未达到这一愿景。正如本文所示，我们几乎没有工具来确保执法具有有意义的政治问责——但我们也没有手段来保护执法免受不当影响。事实证明，在现行法律下，执法既过于独立，又不够独立。

概述

美国法律及法学研究专注于民主合法性的问题。当政府以立法身份行事时，合法性植根于公共问责制。[1] 在此背景下，选举似乎至关重要，事实上，我们各级政府层面的立法者均由选举产生。[2] 相比之下，当政府以裁决身份行事时——即解释和适用法律而非制定法律——问

责制通常会与其他价值（包括独立性）进行权衡。[3]（这里指的是司法）在这里，选举更具争议性，因为让裁决者回应公众压力的想法与我们将司法视为区别于普通政治的愿景格格不入。[4]

【执法是介于立法与司法之间的政府职能】

人们对连接立法与法律适用的政府职能——执法——的关注要少得多。美国政府（包括州和联邦）严重依赖事后执法来落实法律指令，将“书本上的法律”转化为“行动中的法律”。[5] 部分出于这个原因，在许多领域，我们授权私人公民通过提起诉讼来维护其权利，从而参与执法。[6] 但执法也是政府的核心职能。每天，行政官员（同样包括州和联邦）调查可能的违规行为，并在司法或行政程序中寻求制裁。评论家称之为“公共执法”[7] ——这一术语既区分了私人行为者的执法，也简略地传达了政府执法代表公共利益这一熟悉的概念。[8]

尽管其重要性显而易见，但我们缺乏一个理论框架来评估公共执法的合法性，或将其置于我们更广泛的民主治理方案中。因此，执法在运作时不受我们在其他背景下为促进和管理政府问责制而制定的保护措施约束。请考虑以下情况：

与建议的行政法规不同（后者受公众通知和评论要求的约束），执法政策很少公开披露，更不用说公开论证了。例如，实证研究揭示了联邦民权执法重点的转变：从种族歧视转向宗教歧视，然后再转回来。[9] 但是，新的法规或条例通常伴随着 lengthy 的解释和公开辩论，而执法政策的变化往往只有在事后才能被察觉。[10]

与许多监管行动不同，针对执法政策和优先事项的总体决策，不存在正式的集中行政分支审查程序。时任总检察长格里芬·贝尔（Griffin Bell）在 1977 年写道：“虽然我是行政分支的首席法律官，但我发现，除了在与未决诉讼间接相关的情况下，我对司法部以外的律师几乎没有控制权或指导权。”[11] 而且，虽然联邦执法随总统政府的更迭而变化是毋庸置疑的，但总统在执法政策制定中的作用是临时的，且很大程度上不为人知。[12]

与许多受州法律禁止亲自募集竞选捐款且必须回避涉及捐款人案件的当选法官不同，当选的州总检察长（AGs）能够也确实向执法目标对象募集捐款，并参与涉及捐款人的调查和执法行动。[13] 在最近的一个案例中，一项多州调查的目标对象抱怨称，收到了参与该行动的总检察长办公室多次发出的捐款请求。[14]

与影响立法和监管的努力不同，与联邦和州执法者的游说接触基本上不受监管。与此同时，报告显示，执法者——尤其是当选的州总检察长——受到游说者的大量压力，试图影响其执法决定。[15]

执法在披露、监督、选举和游说方面受到的差别待遇，不仅仅反映了疏忽。它也象征着一种更根本的困难。我将论证，执法兼具立法和裁决的特征，使得熟悉的政治问责概念和对公众意愿的回应显得既不可或缺又令人担忧。

【执法兼具立法和裁决特征，具有两面性】

一方面，执法涉及具有立法和监管特征的政策判断。没有任何公共执法者——至少在美国——拥有资源去追究每一个可能的违法行为。他们必须有所取舍，设定优先事项和目标。这些彻头彻尾是政策问题，其解决方式在某种意义上是"政治的"，这不仅不可避免，而且是恰当的。因此，问责制无疑是执法故事的一部分。

另一方面，执法的某些方面似乎更像裁决而非立法，使得最强烈的民众控制形式显得不合适。执法决定不仅是大范围做出的；在实际的日常实践中，执法是一项零售业务。例如，在决定打击欺诈者之后，执法者必须随后决定是追究这个违法者还是那个，是寻求这些救济还是那些。而且，鉴于绝大多数政府执法行动是通过和解而非司法判决解决的，执法者经常既要决定目标也要决定结果。[16] 执法的个性化和追溯性性质使其区别于前瞻性的、普遍适用的立法，并使问责制问题的答案复杂化。政府的执法目标选择以及每个案件中的处罚应受制于公众或政治的反复无常，这种观念确实令人感到不安。

本文发展了一种民事执法的问责制理论，旨在理清这些相互竞争的观点。我解释道，**执法是一种自由裁量性的政策制定形式，对受监管实体和监管受益者都具有重大且往往广泛的影响**。与私人行为者的执法不同，公共执法旨在——也被期望——服务于公共利益。[17] **政治问责机制有助于确保公共执法履行其预期目的**，并满足基本的民主imperative，即"那些可能受集体决定影响的人应有机会和能力去影响该决定"。[18]

然而，**这并不意味着执法者应成为公众反复无常的奴隶。借鉴更广泛的政治代表理论，我认为公共执法可以"代表"公众，而无需在每种情况下都鹦鹉学舌般地重复公众意见**。事实上，**如果公共执法要服务于公共利益，一定程度的自主性是必不可少的。**

将执法视为一种政治代表形式有助于解决上述理论张力，表明问责制和独立性可以在执法背景中共存。但这也凸显了设计执法机构的挑战：**既要促进问责制，又要保留独立专业判断的空间**。这是一项巨大的任务，而我们远未完成。

正如本文所示，现有的规则和实践使得执法的问责程度远低于通常的假设。当我们用来让公众在立法中发声的各种机制被用于政府机构执法时，它们要么被削弱，要么完全失效。更糟糕的是，我们在使执法免受狭隘私人利益影响方面做得太少。尽管在关于“俘获”（capture）的文献中 largely 被忽视，但我表明，执法的几个特征使其特别容易受到私人影响。在这里，我们的传统解决方案也 largely 不可用。如上所述，很少有州将游说法规扩展到执法背景；此类规则适用于影响立法制定的努力，而非实施。同样，执法通常被豁免于“阳光”要求和其他旨在促进政府透明度的规则。此外，虽然一些民事执法者（大多数州总检察长）是选举产生的，但对于如何规范这些选举——即如何在追求问责制与避免偏见和不当影响之间取得平衡——的问题，人们只给予了极少的关注。

本文分为四个部分。第一部分提供必要的概念背景，勾勒问责制在民主治理中的作用，并描述随着我们从一种政府职能转向另一种职能，这一作用如何变化。第二部分论证执法背景下问责制的规范性理由。第三和第四部分从理论转向实践，揭示目前构成的公共执法既未对公众充分问责，也未充分免受狭隘私人压力的影响。

在继续之前，有必要说明一下范围。本文聚焦于执法的民事方面。我不涉及刑事检察官或警察的工作。这一限制的原因符合贯穿全文的直觉：健康的问责制在不同背景下可能意味着不同的事物，取决于所涉及的政府职能。[19] 一些刑法学者已经考虑了检察官的问责制问题，我在适当时候借鉴了他们的工作。[20] 但是，鉴于民事和刑事执法之间的重要差异，在刑事领域行之有效的理论不一定能转化到民事领域。[21] 即使我们对刑事和民事执法的规范性理想相同，我们为确保这些目标而选择的手段也可能不同。

虽然本文将刑法搁置一旁，但它考虑了州和联邦政府的民事执法。这样做部分是为了说明美国法律体系在管理公共执法与公众意志关系方面所采取的各种方法。这种差异本身并非坏事。相反，政治问责制的最佳轮廓可能因司法管辖区而异，取决于每个政府如何构想执法职

能。我将在结论中回到这一点。然而，有一点是明确的：我们目前的执法方法远非最优。

一、绘制问责制图谱：为何、对谁、以及为何事？

问责制或对民众回应的概念应在民事执法中发挥什么作用？在何种情况下（如果有的话），公共执法者应有意识地忽视公众偏好？要回答这些问题，我们首先需要了解执法和问责制在我们政府体系中的位置。本部分聚焦于问责制；文章主体将考察此处描述的概念如何适用于执法。

A. 政治问责制与代表制

现代社会的规模和范围使得直接民主不可行。相反，人民通过其政治代表进行治理。正是通过代表制，人民在政府中被"呈现"。[22] 但当然，人民并非真正在场；他们并非亲自从事治理工作。代表制概念核心的这种二元性——要求人民同时在场又不在场——困扰了数代政治理论家。然而，主流的代表制理论有一个共同核心：要使代表具有"民主性"，他们必须以某种方式获得人民授权，代表人民行事，并且必须有某种方式使人民能够就其行为追究代表的责任。[23]

选举在此框架中占据重要地位。[24] 选举使人民能够选择其代表，并就其任职期间的行为奖励或制裁他们。而且，由于选举是定期举行的，它们"允许选民持续影响其代表的决定"："在任何时间点，政府都有兴趣在其当前决策中考虑选民对这些决策的未来评判。"[25] 通过这种方式，选举确保代议制政府对被代表者的利益具有回应性。[26]

但政治问责制不仅仅关乎选举或预期制裁——即追究代表责任。**传统的问责制定义还表明解释和论证起着关键作用——即要求政府说明责任**。事实上，"迫使人们解释他们做了什么或许是使他们承担责任的基本组成部分……[问责制的核心成为问责者与被问责者之间的对话，使用共享的'论证语言'。"][27] （要求相公众解释也是政治问责制的要求）

问责制被理解为既包括追究责任也包括要求说明，它促进了各种民主价值。从概念上讲，政治问责制构成政治代表制；它使谈论"由人民"治理的政府成为可能。[28] 更工具性地讲，问责制是达成目的的手段——一种确保政府代表保持"在美德之路上"、以人民利益行事的方式。[29] 问责制还通过鼓励公众对治理的审议和参与来培养民主公民身份。[30]

出于所有这些原因，政治问责制是大多数代议制民主论述的核心，是"政府行动合法性的必要条件"。[31] 然而，**这并不意味着所有政府行动都必须问责，或以相同方式或相同程度问责**。首先，必须区分不同类型的问责制。问责制是一个关系性概念；除非指定相关行为者对谁负责，否则它毫无意义。正如目前的讨论所表明，我此处的焦点是政治问责制——即政府对人民的问责。政治问责制可以是直接的，如民选官员的情况。它也可以是间接的或中介的，如政治任命官员的情况。[32] 也就是说，如果相关行为者本身并非民选，他们可能对民选官员负责，或者其行为可能以各种方式受到代表力量的控制。[33] 无论哪种情况，关键——从定义上讲——是"问责持有者"是人民本身。[34]

更困难的问题涉及**问责制、代表制和回应性目标与独立性、专业知识和可预测性等补充价值之间的适当平衡**。美国民主从未追求将政治问责制排除一切其他价值。相反，平衡取决于所涉及的政府职能。

B. 问责制与独立性的权衡

问责制倾向于在立法背景下占据首要地位，[35] 反映了民主原则，即"所有受集体决定影响的人都应有机会影响结果"。[36] 由于立法具有普遍适用性，受法律影响的每个人都"在其通过中拥有直接发言权"是"不切实际的"。[37] 我们人民通过我们的代表参与立法过程，我们的"权利在复杂社会中得以保护的唯一方式是[我们]对制定规则者的权力，无论是直接的还是间接的"。[38] 因此，政治问责制被载入联邦和州宪法，这些宪法仔细规定了立法者民选的方法。正如我们所见，选举"处于美国政治体系的核心"，至少就立法而言。[39] 反过来，选举的中心目标"是准确登记相关选民的偏好"。[40]

裁决程序受制于一套非常不同的规范。在裁决中，正当程序要求受影响的个人获得程序通知并有机会被听取意见。[41] 正当程序还要求执行裁决任务的政府官员保持中立和公正——偏向任何一方都将导致丧失资格，外部影响受到严格限制。[42] 与立法者不同，裁决者不应回应公众偏好。我们期望法官"无所畏惧、无所偏袒地适用法律"[43] 并在必要时"敢于对抗民主中通常至高无上的东西：公众意愿"。[44] 正如最高法院所解释的，"[裁决程序中的这一中立性要求保障了程序性正当程序的两个核心关切，即防止无正当理由或错误的剥夺，以及促进受影响的个人在决策过程中的参与和对话。"][45]

当然，立法与裁决之间这种清晰的二分法过于简单。正如无数人

所观察到的，立法与裁决之间的界限充其量是模糊的。[46] 立法可能 narrowly 制定，针对可识别的个人和群体。[47] 而且，特别是当裁决决定受制于先例原则时，个别案件的决定可能具有广泛的前瞻性影响。在我们后现实主义的世界中，我们知道裁决者所做的不仅仅是以机械的、前政治的方式适用现有法律。[48] 裁决者往往别无选择，只能制定法律——有时会引发"从 bench 立法"的指控。[49]

【行政机关整合了立法与裁决，但缺少各自的问责制，存在合法性危机】

尽管存在这些复杂性，立法与裁决之间的区别仍然是我们法律体系的核心。在行政国家中这一点最为明显。[50] 行政机构通过在同一个机构中结合立法和裁决职能而引发了几乎无尽的学术忧虑和辩论，该机构既不像立法机构那样具有问责性，也不像法院那样独立。尽管机构有权颁布运作方式与立法相似的法规，但它们不受与民选立法者相同的民主制衡约束。学者们认为，这种制度结构"提出了严重的合法性问题：我们如何确保未经选举的行政官僚机构的民主回应性？"[51] 机构裁决提出了另一种合法性问题，因为行政裁决者缺乏我们通常与法官相关联的隔离保护。我们如何确保为同时担任监管者和检察官的同一机构工作的法官的公平性和中立性？[52]

艾伦·莫里森（Alan Morrison）用一句简洁的话总结了这一切："行政机构就像立法机构和法院——除了它们不是的时候。"[53] 然而，请注意这张图景中缺少了什么：**执法。机构不仅制定规则和裁决争议。它们还充当执法者。机构进行调查、选择目标，并在司法或行政场所启动执法程序**。然而，执法引发的关注远少于规则制定或裁决。像其他不属于那些更知名范畴的机构职能一样，执法 simply"被委托给机构自由裁量权"，基本上不受监管。[54]

执法也显著缺乏理论化。尽管当政府监管或裁决时，人们对民主问责制和决策独立性问题投入了大量关注，但我们缺乏同等的执法理论。本文旨在填补这一空白。

二、公共执法中的问责制与独立性

就评论者关注民事执法问责制的程度而言，他们已将其用作一种

比较手段。问责制是区分公共执法（即由政府控制的执法）与私人原告和律师诉讼的一个关键特征。私人各方可能声称在执法行动中代表公共利益，但这种代表至多是虚拟的。评论家强调，"提起私人执法诉讼的公民和裁决这些诉讼的法官都不受选举约束。"相比之下，这些相同的评论家断言，政府机构"通过总统……以及更间接地通过国会监督，对选民负责。"因此，论点认为，"私人执法可能会削弱美国治理的一个有价值的民主特征。"

对私人执法的批评假定，实证上，公共执法者以某种有意义的方式对"人民"负责；规范上，他们应该如此。但这些假设仅仅是假设。很少有人停下来问公共执法者是否真的负责；或者他们是否应该负责，以及在多大程度上负责。

本部分发展了一种公共执法的问责制理论。A 小节通过与立法类比，开始论证问责制的规范性理由。B 小节通过将执法比作裁决并强调单纯引导公众舆论的执法体系的困难，使情况复杂化。C 小节提出了一个和解框架。关键举措是将公共执法不是孤立地思考，而是作为我们政府治理我们的方式之一。我认为，如果公共执法"代表"公共利益这一熟悉的概念有任何意义，它必须指的是一种政治代表形式。民主理论家长期以来一直在纠结关于政府与公众意志之间最佳关系的问题，他们的答案对执法具有启发性。将执法理解为政治代表表明，公众偏好在塑造公共执法方面确实发挥着作用。在公民参与且信息灵通的领域（或问题上），如果官员的行为始终与他们的偏好相悖，就很难辩称该官员在代表他们。但在公民不知情或不感兴趣的许多领域，代表可能有理由违背他们的意愿。

A. 支持问责制的理由

在美国政府的三权分立模式中，执法是行政分支的领域。联邦宪法第二条规定总统有义务"确保法律得到忠实执行"——所有各方都同意这一职能包括执法。第二条还包含有关选举的详细规定，明确设想总统将对人民负责。总统反过来监督行政国家的运作，包括执法。尽管学者们继续辩论总统是否有权指导机构行动，但毫无疑问，他或她有权任命和罢免机构高级官员，并至少监督行政政策。

在大多数州，执法权属于总检察长，他们通常是独立选举产生的。关于直接选举州首席执法者（有时称为"人民的律师"）的规定可能表明，在州一级，问责制和民众控制的理由更强。然而，值得注意的是，

许多州宪法也规定选举法官。正如最近的案例所明确的那样，选举的事实并不意味着法官必须以与其他民选官员完全相同的方式和程度对人民负责。虽然选举提供了底线，但它们留下了充足的空间来平衡回应性和自主性。例如，可以说民选法官在处理某些类型的决定时应该回应公众压力，但在其他类型则不必，这是连贯的。对于当选的总检察长来说，或许也是如此。

简言之，联邦和州宪法将问责制明确纳入执法框架，但对于如何在健康的问责制和不当影响之间划清界限，几乎没有提供指导。我们需要问的是，为何事问责，而不是抽象地思考问责制。在公共执法背景下，我们希望政治问责制实现什么？以更工具性的术语思考执法和问责制有助于确定哪里最需要问责制，以及哪里最令人担忧。正如本小节所解释的，功能性考虑为问责制提供了强有力的理由。执法可以被理解为一种政策制定形式，执法者（包括公共和私人）在手段和目的的选择上都拥有重大的自由裁量权。公共执法与私人类似物的区别在于，政府承诺能够且将寻求维护广泛的公共利益，而不是将执法集中在私人目标上。旨在确保公共执法具有有意义问责制的措施将赋予人民塑造以其名义进行的执法的机会，并加强公共执法与公共利益之间的联系。

1. 作为自由裁量性政策制定的执法

我们为何依赖政府官员来执法？这个问题看似基础，但至关重要。我们已经看到，独立性与问责制之间的最佳平衡随着政府职能的不同而变化。因此，要理解执法背景下的问责制，我们首先必须理解执法。

首先从执法的一般功能开始。当然，执法可以补偿受害者并以其他方式补救非法行为造成的伤害。但执法更根本的社会目的是威慑。通过揭露和制裁违法行为，执法迫使违法者将其行为成本内部化，从而威慑被告和类似行为者的进一步不当行为。最佳威慑水平（因此也是执法水平）将取决于相关法律的条款和可用的制裁。在法律精心起草且制裁与伤害相匹配的情况下，可能需要完全威慑，执法者应追究每一次违规。然而，在许多领域，最佳威慑并不完全。也许法律涵盖了并非真正有害或无法有效威慑的行为。或者也许可用的制裁淹没了任何实际伤害。在这种情况下，我们依赖执法者实行"自由裁量性不执法"——选择他们的战斗，并在适当时候手下留情。

因此，执法是一种重要的政策制定形式。执法可能在正式意义上

不制定法律，但——无论是公共还是私人——执法深刻地塑造了"行动中的法律"。而且在大多数情况下，执法涉及大量的自由裁量要素，因为执法者必须决定是否对任何特定违规行为采取行动，如果是，则寻求何种制裁。

当执法者就优先处理或忽视何种类型的违规行为做出总体决定时，执法所蕴含的政策性质——以及与立法的联系——甚至更为明显。奥巴马政府的暂缓行动计划提供了最近的例子。2012 年和 2014 年，奥巴马总统宣布移民官员将行使"检察自由裁量权"给予"暂缓行动"——即暂时免于驱逐——给某些否则可能受到执法行动影响的移民。这些宣布紧随国会未能通过旨在实现大致相同目标的拟议立法之后。批评者认为，这些计划构成了总统放弃其在忠实执行条款下的职责，也违反了《行政程序法》对规则制定的程序要求。尽管总统 vigorously 捍卫暂缓行动计划的合法性，但他坦率地说明了促使它们的原因："对于那些质疑我权威……或质疑我在国会失败之处采取行动的智慧的国会议员，我有一个答案：通过一项法案。"

考虑一个不同的例子，涉及一项积极的执法倡议，而非不执法政策。政治学家保罗·诺莱特在其关于州总检察长民事执法的近期著作中，描述了总检察长们协调努力改变制药行业设定处方药价格的方式及其广告方式。通过多州诉讼共同努力，志同道合的总检察长们针对并最终扰乱了既定的行业做法，如直接面向消费者的广告和标签外用途的营销。该诉讼在目的和效果上都类似于监管。正如诺莱特强调的，"通过多州和解创造的政策包括几项行业批评者曾在国会提出但从未成功通过立法程序的政策……。和解条款也是对 FDA 对药品营销放松监管姿态的直接回应。"

这些例子说明了监管与执法之间的功能相似性：这两种机构行动形式有时是达到同一目的的替代手段。如果机构想要以某种方式调整监管现状——例如，对被监管实体施加新的要求——它可以修改相关法规，也可以加强其执法努力。实际上，对被监管方的后果可能大致无法区分，特别是当执法导致命令或协议要求被告在未来改变其行为时。正如一位总检察长所说，"总检察长们在顷刻间造成的损害可能比立法机构所能造成的还要大。"执法的这一特征引发了"诉讼式监管"的标签——这是一个用于质疑特定执法倡议合法性的贬义词。

2. 公共执法的希望与风险

将执法批评为伪装监管的观点绝不限于公共执法；它同样有力地延伸至私人各方和私人律师的执法。但是，虽然公共和私人执法都有推动政策的能力，但它们推动的方向可能不同。由于公共和私人执法者在各个方面存在差异，我们可以预期它们以不同方式行使自由裁量权，追求不同的目标并优先处理不同的事项。[87] 这些差异触及我们人民为何如此依赖公共执法的核心，并凸显了对问责制的需求。

大多数关于私人诉讼的论述都从一个共同前提出发：私人执法由诉讼人及其律师的经济激励所驱动。[88] 按照这种观点，原告只有在预期回收超过诉讼成本时才会起诉。[89] 同样，私人律师只有在预期回报超过成本时才会受理案件。[90] 诚然，评论者有时会承认私人诉讼人可能受金钱以外的目标驱动——如复仇、希望被倾听或拥有"出庭日"等目标。[91] 然而，与主导大多数论述的经济利益一样，这些非经济利益具有一个共同特征：它们是个人的、个性化的、私人的。[92]

至少自史蒂文·沙维尔（Steven Shavell）那篇描述"使用法律系统的私人与社会动机之间的根本分歧"的著名文章以来，私人诉讼可能以促进私人利益为代价牺牲公共利益已成为执法文献中的信条。[93] 公共执法则不同——或者至少可以不同。公共执法机构不是营利性企业；它们不必在每起案件中收支平衡，更不用说最大化回收了。政府律师领取薪水，他们的年实得收入与他们选择追究的案件数量或质量、或他们回收的判决金额没有任何直接联系。[94]

政府律师服务的客户类型也与私人律师界的同行不同。公共执法行动中的客户通常是政府官员和机构，他们本身有义务服务于公共利益。[95] 而且，在某些情况下，唯一的"客户"就是公众本身。[96] 例如，当州总检察长决定提起诉讼以补救对该州公民的某些伤害时，没有机构充当公众与律师之间的中介。律师以州及其公民的名义行事，她的义务是对一般公众的。

因此，虽然公共执法者与其私人同行一样必须权衡每次执法行动的预期成本和收益，但他们的考量是不同的——或者至少可以是不同的。私人执法者关注私人成本和收益，而公共执法者可以考虑案件更广泛的社会后果，包括对被告、第三方和整个系统的成本和收益。[97] 换句话说，公共执法可以代表公共利益。

也许要论证公共执法问责制的理由，说到这里就足够了。私人诉讼不会可靠地服务于公共利益；某些利益将被遗漏。我们需要某种方

式让公众本身在执法中得到代表。然而，似乎显而易见的是，这种"代表"不会是传统律师 - 客户关系性质的。与立法一样，全体人民联合起来提起诉讼是不切实际的。我们也无法集体监督和指示律师，或如果我们不赞成她的诉讼选择就在中途替换她。相反，如果政府要在执法中代表我们，这种代表必须是政治性的。正如第一部分所解释的，政治代表通常需要政治问责制。也就是说，这种制度安排——政府行为者从事自由裁量性政策制定以服务于公众——触发了"大多数当代民主理论核心的基本规范直觉：那些可能受集体决定影响的人应有机会和能力去影响该决定"。[98]（公共执法是一种政治性代表，因此应触发政治问责）

如果我们考虑公共执法的现实，承认各种力量可能使公共执法偏离对公共利益的追求，这一论点会变得更强。与其他政府职能一样，公共执法可能因执法官员自身的私利或狭隘的私人利益而被转移。[99]

关于公共和私人执法之间权衡的评论经常强调政府律师可能优先处理推进其个人或职业利益的案件的风险。[100] 公共"律师，像大多数人一样，认识到他们今天的工作表现会影响他们明天的职业机会。"[101] 后果难以预测。根据其个人偏好和职业计划，律师可能喜欢可能引起关注的高调案件的挑战，[102] 或者他们可能更喜欢专注于容易获胜且将低于政治雷达的小型案件。[103] 就当前目的而言，重要的一点是，执法官员的私利与有效执法的公共利益之间没有必然联系。（公共执法存在被官员私利影响、扭曲的风险）

执法被私人影响扭曲的风险至少同样强烈，尽管它受到的关注较少。在立法背景下——特别是行政监管——对私人影响的担忧激发了各种机制，旨在最小化政府被组织化利益"俘获"的风险。[104] 俘获的概念 notoriously 难以把握，但一个良好的工作定义将俘获理解为"结果或过程，通过该过程，监管（在法律或应用中）因行业本身的意图和行动而持续或反复地从公共利益转向被监管行业的利益。"[105]（监管俘获的定义，把公共利益转化为被监管行业的利益）早期的俘获分析倾向于关注过度监管的潜力，但最近的学术研究强调了所谓"腐蚀性"俘获的相应风险，即"组织化公司使监管不如立法所意图的或不如公共利益所建议的那样有力。"[106]（监管在本文中指立法过程，执法指执行过程）

这些定义中对监管的强调并非偶然。大多数关于俘获的评论都集

中在政府的立法职能上，低估了执法。[107] 然而，执法的几个特征使其特别容易受到俘获，尤其是"腐蚀性"类型。执法行动经常反映一种不对称模式，执法成本落在狭窄的被告群体上，而收益由"不注意的公众"广泛分享。[108] 这种模式促进了俘获。众所周知的集体行动问题使大群体难以组织，特别是当对每个个人的成本（或收益）微乎其微时。[109] 较小的群体可以更容易地组织，并且他们有充分的激励试图影响直接影响他们的政府行动。[110]

执法权也倾向于至少最初由专门机构而非通才机构持有。[111] 出于各种原因，通才机构往往比特化机构更不容易受到俘获。根据定义，通才机构处理一系列问题，这意味着它们听取各种利益相关者的意见。由此产生的杂音使任何单一利益难以夺取机构决策的控制权。特殊利益群体从通才机构那里获得的回报也较少，因为即使他们成功了，俘获的"收益也会被对特定特殊利益群体无关的广泛事项所稀释。"[112] 相比之下，专门机构反复处理相同的问题，这意味着它们始终与同一组参与者互动。[113] 从利益集团的角度来看，这种结构既降低了俘获的成本，又增加了俘获的收益。[114]

最后，俘获在执法背景下可能特别难以察觉。为了使任何俘获指控有意义，仅识别与特定利益（如被监管行业）一致的政府行动是不够的。人们还必须识别反事实：相关机构未服务的公共利益。[115] 这在最好的时候都很难做到，但在处理离散的执法决定时尤其具有挑战性。即使人们能在陈词滥调层面识别公共利益——"促进竞争符合公共利益"——要证明机构追究一个被告而非另一个，或寻求这种救济而非那种救济会更好地服务公共利益，是极其困难的。

执法的这一特征不仅使人难以在俘获发生时发现它，而且还使潜在的被告更容易说服公共执法者在其案件中视而不见。正如最近的评论所强调的，在政府官员可以告诉自己他们在做正确事情的情况下，俘获风险可能尤为明显。"大多数腐败行为并不采取明显不道德选择的形式。人们会与那些行为作斗争。"[116] 然而，即使是拥抱服务公共利益职责的官员也可能被所谓"文化"、[117] "社会"[118] 和"信息"[119] 俘获的"软压力"所动摇。善意行事的官员"可能依赖受影响实体提供的信息，缺乏怀疑性审查这些信息的手段或能力。或者机构可能开始以其监管实体看待世界的方式看待世界。"[120] 结果是，政府官员（包括执法者）"可能做出决定，因为他们对公共利益的概念已被行业殖民化。"[121] 值得注意的是，这些决定通常也将服务于政府执法者的私

利。[122] 如上所述，政府律师可能希望在被监管行业获得政府后就业，或者他们可能希望避免特别困难和有争议的案件，这些案件可能耗费时间和精力却没有成功的保证。执法者同样可能渴望以令人印象深刻的胜诉案件和达成的和解统计数据来取悦其监督者。出于所有这些原因，与强大且高度 motivated 的被告作战可能显得 decidedly 没有吸引力。[123] 在这种情况下，善意的执法者可能被以下说法所动摇：最困难的案件或最严厉的制裁实际上不会促进公共利益。

这一分析表明，执法背景下的俘获风险是真实的，值得作为独立课题进行研究。它还有助于强调公共执法问责制的功能性重要性。问责制可以将公共执法与公共利益绑定。也就是说，问责制有助于确保公共执法者确实关注执法的全部社会后果，而不是强调主导私人执法的更狭隘、更偏狭和更财务的关切。当然，政治问责制并非实现这一目标的唯一手段。道德和职业规则强制律师为其客户的利益工作，而且——如上所述——政府律师的相关"客户"往往是公众本身。[124] 官僚控制（包括办公室政策和规范）可以帮助强化这一焦点。[125] 但旨在将执法者与其声称代表的公众、或与本身与公众相连的政治代表联系起来的制度结构，也可以发挥作用，巩固公共执法与公共利益之间的联系。

B. 执法与独立性

我已论证，如果公共执法要“代表”公共利益，那么问责制至关重要——无论是出于概念性还是后果性的原因。但这里存在一个潜在问题。问责制的目标是使政府对公众负责。然而，在执法背景下，政府行动将引导公众意志这一观念令人感到不安。刑法学者在撰写关于民选检察官的文章时已指出了这种张力。[126] 民法学者认为是民主的东西，这些学者却视为危险。

本小节旨在剖析这种不安背后的直觉。我认为，对不当公众影响的担忧反映了两个相关的考量集合。首先，对公众舆论的回应性可能会破坏与法治及相关中立规范相关联的价值。其次，我们有充分的理由担心，关于执法的公众舆论可能信息不足，或者基于非法的考量，如对特定群体或个人的偏见或恶意。这些担忧很重要，它们应塑造我们组织和管理公共执法的方式。但同样重要的是要认识到，执法在这些方面并非独一无二。相反，正如下一节所解释的，此处描述的挑战仅仅是民主理论中关于政治代表适当角色的更广泛谜题的一种表现

形式。

1. 与裁决的类比

上述讨论将执法比作立法。然而，执法的某些方面似乎更像裁决，从而触发了可能与问责制相冲突的规范——如公正性和判断独立性等规范。

执法的裁决方面在和解背景下最为明显。绝大多数执法行动都是通过和解解决的，通常只有极少（如果有的话）司法监督或参与。[127] 实际上，执法者往往不仅决定追究哪些行动，还决定如何解决它们。在这种情况下，执法者不仅仅是一方的倡导者；他们对决定什么是公平和正义的结果负有重大责任，需通盘考虑。[128]

虽然很难夸大和解的重要性，但即使我们忽略案件解决的实际方式而仅关注目标的选择，与裁决的类比依然成立。关于追究哪些违法者或寻求何种救济的离散决定，涉及可识别的个人或公司的利益。[129] 问题不在于法律未来应该是什么，而在于现有法律是否以及如何适用于特定的一组事实。与法官不同，执法者可能会从倡导者的角度评估这些问题，但他们的评估与裁决者的工作比与制定前瞻性、普遍适用法律的立法者的工作有更多的共同点。

在这方面，请考虑法院为何允许拥有民选司法机构的州对司法选举采取比第一修正案对“政治选举”所允许的更严格的监管规定所提供的理由。[130] 在处理“政治家”的选举时，法院驳回了国会和各州应能够监管竞选捐款和支出以最小化或平衡财务支持者影响的论点。在法院看来，“偏袒和影响……在代议制政治中是不可避免的……人们充分理解，投票支持或向一位候选人而非另一位候选人捐款的实质且合法的理由（如果不是唯一理由的话），是该候选人将通过产生支持者青睐的政治结果作为回应。民主建立在回应性的基础之上。”[131]

法官则不然。法院已承认各州在防范政府“腐败”方面具有紧迫利益。[132] 由于司法职位的性质不同于政治职位，因此关于什么会腐蚀它的考量也不同。法院认为，“讨好和接触……在政治背景下不是腐败”，而是“体现了民主的核心特征”。[133] 然而，司法背景则不同：“在裁决案件时，”法院坚持认为，“法官不应遵循其支持者的偏好，也不应向其竞选捐款人提供任何特殊考虑。”[134] 因此，“被赋予行使严格中立性和独立性的法官，如果不乞求竞选捐款人，就不会损害公众对司法诚信的信心。”[135]

法院关于法官所说的许多话也适用于执法者。例如，在维持禁止司法职位候选人亲自募集竞选捐款的州法律时，法院观察到，司法候选人的“个人募集‘不可避免地使被募集者处于这样一种位置：如果他们未能 financially 支持该候选人，就会害怕遭到报复’。”[136] 类似的风险也出现在执法背景下。考虑最近的一个例子。2013 年初，来自三十多个州的总检察长对生产含咖啡因饮料"5-Hour Energy"的公司可能存在的虚假广告和欺骗性营销展开了调查。[137] 据该公司称，随后它开始收到向参与调查的总检察长提供竞选捐款的请求。[138] 高管们将这些募集比作索要“赎金”。[139] 诚然，这种说法是自利的，应持保留态度。但无论是否被索取，记录显示，5-Hour Energy 在 2013 年和 2014 年向 various 总检察长的政治基金捐赠了超过 28 万美元。[140]

这样的故事在执法和裁决背景下尤为尖锐，因为在这些背景下，政府官员被要求做出涉及离散且可识别的个人和群体的决定。虽然私人资助的竞选活动的现实可能在任何情况下都会引发对偏袒或报复的担忧，但当政府通过普遍适用的立法或监管行事时，这些担忧会减弱。即使竞选捐款人对立法者有特殊接触和影响力，他们努力的成果也会惠及他人：任何法律都将影响竞选支持者和反对者。相比之下，在执法背景下——如同在审判中一样——我们可以想象最糟糕的“权钱交易”情景，即政治支持者受到优待，而反对者受到惩罚。[141]

仅仅是这种情景的可能性就足以破坏公众对司法中立管理的信心。[142] 虽然执法者作为倡导者的地位意味着他们不像法官那样受制于同样“严格”的中立要求，[143] 但他们有义务成为广泛的——而非捐款人或任何其他私人利益——公共利益的倡导者。事实上，法院长期以来一直认为，政府律师必须至少在两个方面保持“公正”：“他们必须寻求真相而不仅仅是获得定罪”，并且他们的“起诉决定应基于证据，不得对任何群体或个人存在歧视或偏见”。[144]

也许并不令人惊讶的是，关于这个问题的大多数讨论都集中在刑事起诉上，那里“自由本身可能岌岌可危”。[145] 然而，最高法院已认识到，民事案件中的执法决定“可能导致被告或法定受益人承担重大负担，即使他最终被证明无罪”。[146] 因此，法院明确表示，在民事和刑事案件中，政府律师可允许的“党派性”是有限度的。[147] 由此推论——paraphrase 法院关于法官的言论——政府律师“在选择执法案件时，不应遵循其支持者的偏好，也不应向其竞选捐款人提供

任何特殊考虑”。[148]

2. 公众舆论的尴尬角色

5-Hour Energy 的故事可以被理解为俘获的重演——一个私人影响（或执法者私利）威胁压倒公共利益的例子。然而，我想表明，教训比这更深。也就是说，与审判的类比也应让我们对公众影响有所顾虑。

想象一下，政府官员可以获得关于某个问题的民意调查结果。调查结果——如果有的话——应在官员的决策过程中发挥什么作用？大多数评论家会同意，民意调查可以是立法决定的合法输入，尽管他们可能就立法代表是否可以仅参照公众舆论来为其决定辩护存在分歧。[149] 如果相关官员是法官，共识可能会从赞成转向反对。[150] 那么执法呢？政府执法者能否恰当地根据民意调查结果来决定追究特定目标或寻求特定制裁？这个问题的答案似乎介于立法者和法官的答案之间，而且——具有启发性的是——犹豫的原因与我们在司法背景下可能给出的原因相似。

首先，许多法律旨在保护个人免受多数人意志的侵害。反歧视法是最清楚的例子，但绝非唯一的例子。允许这些法律的执行取决于多数人的偏好，将歪曲其目的并削弱其效力。正如最高法院曾经指出的那样，一个人的“权利不得交付投票；它们不取决于任何选举的结果”。[151] 当然，法院谈论的是审判。但案件不会凭空出现在法院的日程表上；它们来到法官面前是因为原告（公共或私人）选择主张相关权利。如果执法决定由大众需求控制，我们的法律将遭受同样的损害，就像司法决定由人民投票产生一样。

其次，执法决定可能具有高度自由裁量性，但并非没有标准。[152] 司法滥用自由裁量权的传统标志之一是未能考虑相关因素，或依赖无关因素。[153] 类似的概念可以指导执法。对被执行法律及其背后目的的分析，通常会产生一系列指导自由裁量权行使的因素。威慑本身的目标也为决策提供了一个框架。（约束执法决定的因素：被执行的法律+最佳威慑）对于我们假设的民意调查来说，最简单的情况是调查揭示了威慑计算，或告知了实证法认为相关的考量——例如，通过传达关于某些行为造成的伤害的信息。即使在这种情况下，公众舆论也只是执法计算中的一个因素，可能会被相互竞争的考量所压倒。将公众舆论视为独立的充分决策基础，而不仔细权衡相关法律的目的或如

何最好地促进威慑，将破坏公共执法的核心功能：服务于公共利益。

第三且密切相关的是，执法决定也是法律决定。[154] 当执法倡议依赖于对相关法规的特定解释时，这一点最为明显。然而，即使执法者在公认允许的解释范围内工作，他们关于追究哪些违法者或寻求何种制裁的选择，也会对法律在实践中的含义产生深远影响。这些选择应基于原则，而非意志；它们不应是任意的。[155] 我们对法治的承诺包含了对同类案件同等对待的承诺。在不可能的情况下（也许是因为资源限制或对过度执法的担忧阻止执法者追究某一类型的所有违规行为），选择一个案件而非另一个案件的理由至少应能够概括化。[156] 同样，公众舆论有时可能反映此类理由。但一种仅适用于一个案件的执法理论，无法与支撑法治的一致性、可预测性和公平通知价值观相协调。

最后，公众舆论经常是误传或不知情的。它可能基于关于法律或相关行为的错误前提，或者基于法律认为无关的考量。公众可能缺乏执法者可以获取的信息和经验。更糟糕的是，公众舆论可能基于法律禁止的考量：例如种族偏见，或个人恶意。在针对可识别目标的个案决定中，这些担忧尤为突出。普通公众很少拥有必要的信息和专业知识来判断追究一个案件而非另一个案件是否能更好地服务执法目标。同时，决定越有针对性，偏见和其他不当动机的风险就越大。正如当时的埃琳娜·卡根（Elena Kagan）教授所写："正是在这个领域，因为如此专注于特定的个人和公司，最粗俗的政治形式（在极端情况下涉及个人恩惠和宿怨）对取代专业精神并由此破坏对法律决策的信心的危险最大。"[157] 卡根当时是在反对总统对离散执法决定的控制——这是她对"总统行政"一般支持的例外。[158] 但这种担忧超越了总统的干涉，也不限于"个人恩惠和宿怨"。[159] 根据其基础，广泛的公众情绪也可能成为执法的非法理由。正如我们会谴责基于公众惩罚特定被告愿望的司法决定一样，我们也应不赞成那些呼应愤怒暴民的执法决定。

C. 作为政治代表的执法

所有这些都有助于解释为何将执法描述为"政治的"很少是一种赞美。[160] 但在此处，我们发现自己似乎陷入了僵局，因为执法确实是政治的——这是不可否认且不可避免的。我们的制度并非德国的强制起诉制度（在该制度下，执法者被期望追究每一次违规）。[161] 这

并非疏忽，也不是因资源有限而不得不接受的恶行。我们依赖公共执法者行使自由裁量权，将往往过于宽泛或僵化的法规和条例转化为现实生活中可行的规则。

对此困境的一种可能回应是强调卡根（Kagan）及其他人在总统控制执法背景下所划分的广泛政策与个案决策之间的区别。也许政策决定应对公众压力做出回应，而个案决策则应免受其影响。困难在于，政策制定与政策适用之间的界限充其量是模糊的。从某种意义上说，政策决定仅仅是个别执法决定的聚合。除非且直到执法者遇到提出这些问题的案件，否则某些政策问题甚至不会出现在他们脑海中。个性化的执法决定可能是关于政策的决定，反之亦然。[16 2]

我想提供另一种前进路径。如果我们将执法视为更大治理体系的一部分，我们就可以认识到本部分勾勒出的张力是一种熟悉的张力。关于政府行动与公众意志之间关系的这种类似矛盾心理，反映在关于政治代表性质的古老辩论中。如前所述，选举对大多数政治代表理论至关重要：选举促进问责制，进而鼓励政府官员促进他们表面所代表的人民的利益。但是，假设我们距离选举还有几年——比如说，在一个六年任期的第三年。说一个社区被代表得好或不好意味着什么？代表应该遵循其选民的愿望，还是应该为了选民的福祉而行使自主判断？[16 3]

只有当人们坚持认为代表制——以及促进有意义代表制的问责制——要求官员必须完全遵循其选民的愿望时，本部分所确定的挑战才显得无法治愈。但很少有理论家持这种立场。有些人从概念上论证，代表的职责是追求其选民的客观利益，无论选民在任何特定时刻声称想要什么。[16 4] 其他人则从经验现实出发论证，选民对政府必须面对的大多数问题理性地处于不知情状态，在这种情况下，代表几乎没有选择，只能行使自主判断。还有一些人采取更细微的观点，承认如果代表制反复背离被代表者的愿望，那就是误入歧途，但仍坚持代表不必——也不应——在每种情况下都盲从选民的偏好。汉娜·皮特金（Hanna Pitkin）关于代表概念的经典著作 exemplify 了这种方法。皮特金认为，政治代表意味着“以对被代表者负责的方式，为了被代表者的利益行事”。[16 5] 通常，这意味着代表必须按照选民的偏好行事——前提是选民有偏好的话。但并非总是如此。“领导力、紧急行动、针对人民一无所知的问题采取行动，是代议制政府的重要现实。它们不是对真正代表制的偏离，而是其本质。”[16 6] 因此，对皮特

金而言，代表的最终义务是做对选民有益的事，而不是遵循他们的每一个愿望。[167] 诚然，选民的愿望与他们的利益相关，在大多数情况下两者是一致的。[168] “因此，”皮特金解释道，“代表也有义务对这些愿望做出回应。他不必总是服从它们，但他必须考虑它们……"[169] 而且，重要的是，“当代表发现自己与选民的愿望发生冲突时，这一事实必须让他停下来思考。这要求他考虑产生差异的原因；这可能要求他重新考虑自己的观点。仅仅做出选择是不够的；选择必须是正当合理的。”[170]

当代理论家继续辩论代表的含义，但大多数人加入皮特金的行列，拒绝最极端的“授权”或“代表”观点（即代表有义务遵循并在必要时征求选民的观点）。[171] 像皮特金一样，他们认识到选民偏好是重要的政策输入。真正的代表意味着代表不会轻易背离选民的愿望。[172] 偏离公众偏好的决定是允许的，但它们必须能够根据公共利益进行辩护。[173]

虽然这种方法是以致代表制的术语表述的，但它延伸至问责制问题。毕竟，问责制是确保有效代表制的一种手段。取决于人们如何构想代表制，问责制不必等同于对公众意志的盲目服从。正如杰里米·沃尔德伦（Jeremy Waldron）所言，“指令是一回事；问责是另一回事。”[174]

应用于执法，这种方法的优势在于，它允许我们将上一节确定的担忧——即对某些党派偏袒或对他人怀有恶意的风险；公众对执法的舆论可能不知情或误传的可能性；多数偏好与被执行法律的目的之间可能存在的张力；等等——纳入代表制和问责制理论之中，而不是与之对立。使得在某些情况下忠于公众偏好令人担忧的考量，恰恰也是那些可以证明背离公众愿望合理性的考量类型。[175] 然而，这并不意味着公众的愿望是或应该是无关紧要的。我们可以连贯地说，公共执法必须问责，必须考虑公众偏好并对此做出回应，同时又不支持执法决定应由民意调查主导的观念。<u>执法决定不应像我们想象司法决定那样对公众舆论视而不见。然而，与此同时，执法的针对性和追溯性性质——即引发对“中立性”呼吁的特征——可能为背离公众偏好提供比立法背景下更强烈的正当理由</u>。

诚然，在实践中确定回应性与自主性之间的适当平衡并不总是容易的。例如，对于某个问题上的公众舆论是误传的，还是仅仅反映了执法者应认真对待的另一种公共利益愿景，理性的头脑可能会有分歧。

这种执法构想的美德不在于它能解决关于特定执法努力合法性的所有分歧，而在于它帮助我们确定我们应该争论什么。

三、实践中的执法问责制

将公共执法理解为政治代表有助于解决上一部分描述的理论张力。但这也凸显了为执法设计有效问责机制的巨大实际挑战。本部分开始这项工作，审视我们现有的法律和制度结构，以评估公共执法在事实上是否问责，以及在多大程度上问责。虽然我提出了一些改革建议，但本部分及下一部分的主要目标是揭示我们目前对执法处理的不足之处。就现状而言，几乎没有理由相信公共执法会对其表面所代表的公众做出回应。更糟糕的是，我们有充分的理由担心公共执法会受到狭隘私人利益的影响。回到上文描述的俘获风险，第四部分表明我们现有的系统存在双重缺陷：虽然公众很难触及执法，但它却容易受到私人压力的影响。

A. 联邦执法：政治控制

没有任何联邦执法者是选举产生的。在缺乏选举的情况下，美国法律和政策倾向于依赖更间接的手段来促进政治问责。这一策略在联邦行政法和学术研究中得到了充分展示，其中问责制一直是一个核心关注点。[176] 在监管背景下，对“未经选举的官僚制定法律”所带来的“严重合法性问题”的主要回应是强调机构人员与民选官员（总统和国会议员）之间的联系，后者有能力影响或控制机构的工作。[177] 本节考虑在执法背景下类似的机制。它表明，我们依赖来使行政监管合法化的政治控制在执法方面要弱得多。

1. 总统

联邦行政分支的统一结构意味着执法权属于总统及其下属。实际的执法工作由专门机构或通才型的司法部（DOJ）处理。而且，正如在监管背景下一样，与总统的联系强度取决于相关机构被归类为“独立”机构还是“行政”机构。[178]

大多数高级联邦执法官员是政治任命者。总统在参议院的建议和同意下任命机构负责人。[179] 对于独立机构，总统任命受到两党要求和委员交错任期的限制。[180] 总统还任命司法部的关键人员，包括总检察长、副总检察长、助理总检察长以及93位美国检察官。[181]

专门机构的大部分法律工作由该机构的总法律顾问及其工作人员处理，尽管有些机构设有专门致力于执法的部门。[182] 在所有行政机构中，总法律顾问都是总统任命者；在独立机构中，一些总法律顾问由机构领导层挑选，一些由总统任命。[183] 然而，即使机构总法律顾问形式上由总统提名，“通常情况下……总法律顾问实际上是由机构负责人选定的，总统尊重其判断。因此，法律顾问的忠诚度可能主要指向机构负责人，其次才是总统。”[184]

高级执法官员在免职保护方面也有所不同：有些人可由总统随意免职，其他人只能因故免职。[185] 在这里，区别通常也遵循行政机构与独立机构之间的界限。例如，美国检察官“由总统酌情任用”[186] 并可被随意免职。[187] 乔治·W·布什总统在2006年行使了这一权力，当时他解雇了七名美国检察官，原因似乎与绩效无关，而完全与党派政治有关。[188] 这些解雇引发了激烈的争议，最终导致国会听证和司法部监察长的调查。[189] 批评者认为，总统违反了长期存在的反对将司法部政治化的规范，该规范允许“在党派政权更迭时大规模更换美国检察官，但禁止中途有针对性地进行免职”。[190] 但法律仍未改变：美国检察官几乎可以因任何原因被免职，包括他们在个别案件中的决定。[191]

在最高级执法官员之下，选举和政治任命逐渐消失。大部分日常工作由公务员完成，他们通常是职业官员，在总统政府更迭期间仍留在岗位上。[192] 根据机构（有时是问题）的不同，职业律师可能在执法选择上拥有相当大的自主权，或者必须在采取行动前将拟议的行动上报给机构高层。

此处勾勒的官僚结构——层级顶端的政治任命者，以及执行大部分关键工作的公务员——正是引发监管背景下民主合法性担忧的原因。[193] 正如第一部分所示，学者们已经产生了海量的评论，试图应对现代行政国家中问责制的挑战。一种回应是加强监管政策与总统之间的联系，主要是通过信息和监管事务办公室（OIRA）正式化对机构法规的集中行政审查。[194] 这种审查被认为是联邦机构政治问责的关键来源。[195]

然而，现有的监管审查工具仅适用于监管。相比之下，执法看起来简直是无政府状态。这一说法可能显得奇怪，因为集中化通常与问责制一起被列为区分公共执法与私人替代方案的特征之一。[196] 乍一看，联邦系统内的公共执法似乎是集中的，因为大多数诉讼权归属

于一个机构：司法部。除非有明确的法定授权，否则机构不得自行提起诉讼或聘请外部（非司法部）律师来做这项工作。[197] 就像集中化的监管审查一样，司法部对联邦诉讼的控制可以从问责制的角度来理解。集中化将诉讼决策引导至“主司法部”（Main Justice）——一个在物理上和理念上都接近总统的机构。因为总检察长“能看到大局——并且用与总统相同的眼睛看大局——集中化确保了法律工作与政府更广泛的政策关切保持一致”。[198]

然而，更仔细的审查揭示了司法部控制作为确保公共执法政治问责手段的重大局限性。首先，司法部的影响只在一个方向上起作用——即抑制执法。司法部可以拒绝追究相关机构提出的执法行动，但如果机构本身选择不采取行动，司法部几乎无能为力。[199] 司法部控制的规则也充满了例外。正如尼尔·德文斯（Neal Devins）和迈克尔·赫兹（Michael Herz）所示，“国会显著削弱了总检察长作为美国首席诉讼官的角色，将至少部分独立诉讼权授予了大约三十六个政府实体。”[200] 仅举几例，劳工部、证券交易委员会和联邦贸易委员会都有权自行提起民事执法诉讼。[201] 虽然独立诉讼权在独立机构中比在行政机构中更常见，[202] 但现有的模式几乎没有规律或道理可言。相反，“独立诉讼权的范围（甚至其存在本身）似乎更多的是随意的而非有目的的。”[203]

使情况更加复杂的是，必须区分诉讼权和执法权。后者包括采取不会最终进入法院的执法行动的权力——包括行政程序。从长远来看，行政程序是联邦机构执法的主要形式。[204] 司法部在行政执法中不起任何作用；决策权掌握在每个机构手中。[205]

同样重要的是，对于关于执法政策的更广泛决定——即关于优先处理或淡化哪些类型违规行为的更广泛决定（相对于决定是否起诉或上诉特定案件）——没有既定的集中行政分支审查程序。正如凯特·安德里亚斯（Kate Andrias）所详述的，不存在类似于（即使是粗略地）正式集中监管审查的系统。[206] 结果是，总统在执法政策中的作用很大程度上是临时的且不为人知的。

当然，临时性的影响仍然是影响，总统确实可以通过更非正式的手段塑造执法政策。但是，自上而下的监督只有在影响线及其后果对公众可见时，才能作为问责工具发挥作用。然而，在执法背景下，透明度是例外而非常态。一项又一项研究表明，随着总统政府的更迭，执法也会发生变化。[207] 反垄断学者经常将执法称为“钟摆”，特别

是在使用反垄断法监管拥有巨大市场力量的主导企业行为的适当性问题上摇摆不定。[208] 民权执法反映了类似的模式，[209] 研究记录了（除其他外）执法者对不同种类歧视（例如种族或宗教）相对重视程度的变化。[210]

其他研究揭示了执法强度的变化。例如，最近的一份报告显示，从布什政府到奥巴马政府，职业安全与健康管理局（OSHA）的检查数量保持相对稳定，但在奥巴马领导下，发出的违规传票数量飙升，在其第一个完整任期内增加了 167%。[211] 同一份报告显示，奥巴马时期的环保署（EPA）根据《清洁空气法》进行的行政执法行动多于布什时期。[212] 然而，虽然环保署在奥巴马政府期间似乎更频繁地评估罚款，但平均罚款金额自布什时代以来已显著下降。[213]

清单还可以继续列下去，但要点应该很清楚：执法政策绝非静止不变，总统的身份至关重要。但是，相关信息浮出水面的过程恰恰是颠倒的。正如第一部分所解释的，问责制的核心组成部分是公众“要求[其代表]说明责任”的能力，即获得对公共政策的解释。我们人民不应依赖学者的实证研究来了解执法战略的巨变，或从负责官员那里引出合理化解释。[214] 至少，当总统的影响不确定且未公开时，很难辩称联邦执法因其与总统的联系而具有问责性。

2. 国会监督

机构行动也受到立法机关中民选代表的监督和控制。立法监督很重要，原因有几个。最明显的是，它提供了另一种间接问责来源，即人民通过其立法代表影响执法的手段。[215] 但立法机关也是“政府信息的主要公共储存库，通过其接收公共机构报告的法定权利以及独立质询和调查的权力。它们……为许多公共辩论奠定了基础，从而促进了更广泛的政府公共问责。”[216]

然而，在这里，当我们从监管转向执法时，影响线也开始变得模糊。[217] 国会对执法的关注在零星和不存在之间摇摆。在某些方面，模式与我们在监管背景下看到的相似。例如，在分裂政府时期（即立法和行政分支由不同政党控制），立法监督比同一政党控制两个分支时更为有力。[218] 同样，立法者更有可能关注高公众关注度的问题。因此，一些机构成为立法监督的 recurring 目标，涉及执法和监管。[219] 其他机构则基本上处于雷达之下——也就是说，直到外部事件（如广受宣传的丑闻或灾难）将它们带入公众视野。[220]

关键在于，虽然立法者有多种手段在法规最终确定前影响机构法规，但对执法的控制几乎完全是事后的，因此效果较差。在监管背景下，通知和评论程序迫使机构在规则定型之前披露拟议规则，使利益集团和持同情态度的立法者有机会介入。[221] 延迟法规生效日期的规则同样“减缓了监管进程，使国会观点的支持者有时间动员并影响政策结果”。[222] 相比之下，执法决定往往作为既成事实呈现给立法机关。立法者可能在事后严厉斥责相关机构官员，但在离散执法决定实施之前，他们几乎无法施加影响。

诚然，未来立法报复的威胁可能会影响执法者当前的行为。毕竟，这就是选举被认为运作的方式。正如第一部分所述，“选举的影响力通过预期反应的间接权力远远超出了选举过程本身”。[223] 也许，对执法的事后立法控制也是如此。

困难在于，现有的立法控制系统既不是为了促进公共执法的有意义问责而设计的，也没有被用于此目的。当然，国会可以通过修改正在执行的法规来改变执法。如果机构正在追究立法者认为不值得谴责的违规行为，立法机关可以收紧相关的实质性条款，以便将来将这些违规行为排除在法规范围之外。如果立法者担心边缘案件的执法，他们可以在最初就仔细且狭窄地制定法规。虽然人们不应对这些可能性过于乐观——关于向机构授权的文献强调了立法往往以宽泛和模糊的术语撰写的多个原因[224] ——但值得注意的是，在民事背景下，制定狭窄法规的可能性比在刑法领域更大。刑法学者对通过立法限制检察自由裁量权感到绝望，原因很简单，犯罪控制的政治是如此一边倒。[225] 虽然各种有影响力的选民群体（包括但不限于检察官自己）从宽泛的刑法中受益，但很少有人提出反论。[226] 被定罪者或潜在罪犯没有游说团体。相比之下，在民事方面，受监管实体确实有游说团体——而且是很强大的游说团体。因此，至少可以想象国会通过限制可触发执法行动的违规行为范围来约束执法。但这些限制将同等有力地适用于公共和私人执法；它们无助于支持这样一种论点，即凭借行政和立法分支之间的关系，公共执法具有独特的问责性或回应性。

一个更有希望的问责来源可以在国会的拨款权中找到。[227] 与私人同行不同，公共执法者在由立法拨款控制的预算内运作。预算编制过程既是“要求说明责任”（提取关于执法的信息）也是“追究责任”（制裁无效或误导性的执法，或奖励有效促进公共利益的执法）的机会。理论上，至少，国会可以利用预算编制过程推动执法朝着期望的方向

发展，将资金用于某些执法倡议，同时扣留其他倡议的资金。[228] 实际上，这种情况很少发生：常态是涵盖各种条款执法的一揽子拨款。[229] 因此，虽然立法者可以利用预算过程表示对特定执法机构的赞成或不赞成——并促进更多或更少的执法——但该工具相对粗糙。

此外，当立法者确实利用预算来控制执法时，他们的指令往往对公众视线以及通常的立法和公共辩论过程 obscured。“限制性附加条款”（禁止将拨款资金用于特定用途的条款）充其量也只是埋藏在冗长的拨款法案中。[230] 更常见的是，关于资金如何使用的指示出现在拨款委员会的报告中，而不是法案的实际文本中。[231]

自我资助执法的趋势进一步削弱了预算控制——这种现象在两级政府中都存在，尽管在州一级更为普遍。[232] 执法机构通常被允许保留部分执法收益，以资助未来的执法工作。[233] 这种安排并不允许机构完全避开拨款程序，但它们在机构的执法政策与立法青睐的年度波动之间提供了重要的缓冲。[234]

最后，也许最重要的是，在预算关切塑造机构行为的范围内，其影响可能主要是适得其反的。联邦机构必须向国会提交年度预算请求，大多数机构利用这一机会大肆宣扬其执法努力。[235] 像任何面临评估的人一样，机构有强烈的动机强调易于衡量的有效性指标。[236] 国会通过要求机构提交年度绩效计划进一步强化了这些激励措施，这些计划以“客观、可量化和可衡量的形式”表达目标。[237]

这一系统的后果既可预测又有害。机构年度报告中的信息绝大多数是定量的——开启的调查数量、结案的案件数量、回收的美元金额。[238] 最近的学术研究表明，这些数字本身往往具有误导性或不可靠。[239] 但更深层次的问题在于分析的性质。机构很少对其执法方法的“为什么”提供深入的解释。[240] 然而，这种定性解释对于关于执法政策的有意义辩论至关重要。关于机构政策选择的透明度也将使国会（和公众）能够评估机构绩效是否与其自身阐述的目标一致。相反，绩效通常以定量术语进行评估。这种焦点不仅阻碍了有意义的披露，而且还影响了执法本身：知道他们必须在财政年度结束时“为饭碗歌唱”（争取预算），机构可能会以使产生良好数据的方式塑造执法政策。[241]

B. 州执法：选举

与联邦模式相比，州一级的执法与人民有着更直接的联系：执法者选

举。43 个州的总检察长（AGs）由选举产生，通常任期为四年。[242] 在七个州，总检察长由任命产生（或由州长、立法机关，或在其中一个州由最高法院任命）。[243]

选举并非一直是州执法者的常态。在后革命时期，大多数州总检察长是任命而非选举产生的。[244] 总检察长选举的趋势根植于与许多州产生司法选举相同的动力：最初是一种使某些官员独立于政府其他部门的冲动，随后是一种更民粹主义的强调，即通过普选作为问责手段。[245] 然而，虽然司法选举是近乎持续辩论和关注的主题，但各州首席执法官的选举受到的关注要少得多。[246]

尽管总检察长选举为州执法政策的有意义问责创造了潜力，但有理由担心其效果更多是理论上的而非现实的。[247] 媒体对总检察长竞选的报道充其量是零星的，候选人自己也很少提供超出表面一瞥的执法计划。[248] 相反，竞选往往聚焦于候选人的个人特征，包括其党派信誉。[249]

部分问题在于，总检察长的职责远不止民事执法。他们还就拟议立法提供意见，以防御身份代表州实体和官员，处理刑事起诉，监督慈善信托——等等。[250] 鉴于这些多样化的职责，可以理解的是，总检察长选举中的大多数实质性政策讨论都停留在高度概括的层面，而不是概述候选人具体打算如何利用执法权。

此外，执法对大多数选民来说可能是一个相对低关注度的问题。[251] 对于民事执法而言或许尤其如此，对于一般执法政策而言更是如此。如果普通公民关注民事执法事项，那很可能是在少数大案要案的背景下，而不是关于如何最好地优化威慑的抽象理论。[252] 然而，吸引选民注意力的案件不太可能反映执法者在日常工作中实际做的事情。

州多元行政分支的结构加剧了这些挑战。也许对统一行政分支最古老的辩护理由是通过将权力集中在单一代表手中来加强问责制。[253] 这种观点表明，众多民选的州官员可能使公民难以识别并追究负责任官员的责任。这是关于多元行政分支的一般性观点，不仅限于执法。但在执法背景下，这个问题可能尤为严峻，因为它将一个低关注度问题与一套特别令人困惑的制度结构结合在了一起。

总检察长的执法权源于宪法、制定法和普通法授权的复杂混合。普通法下的普遍规则是，总检察长既有“义务”也有“专属权利”代表[州]政府及其机构和官员。[254] 一些州宪法和法规编纂了这一规则，赋予总检察长推定有权代表州控制诉讼。[255] 其他州在美国革命后时期

有意识地打破了普通法的方法，转向一个更加分散的体系，允许州机构聘请自己的律师，或者授权州长任命他们。[256] 在一些州，诉讼控制权属于州长，而非总检察长。[257]

即使在遵循将诉讼权集中于总检察长办公室这一普通法传统的州，总检察长的角色也因主题而异。在某些领域——消费者保护就是一个常见的例子——总检察长是主要的执法当局，是先行者。[258] 在其他领域，总检察长代表“客户”机构处理执法的法律工作。[259] 在这种情况下，总检察长对执法政策的控制必然减弱，并且受到法定限制和例外的约束。例如，在阿肯色州，总检察长仅在机构请求时才代表州机构。[260] 几个州将环境执法权授予专门机构而非总检察长。[261] 其他州将民权诉讼排除在总检察长的一般职权范围之外，还有一些州为反垄断诉讼设立了例外。[262] 而且，总检察长对法庭诉讼的控制可能比其对纯行政执法的控制要强得多。

各州在总检察长与客户机构（其中一些机构本身可能由民选官员领导）发生冲突时谁的判断占上风的问题上也存在差异。一些州赋予总检察长最终决定权；另一些州则认为总检察长与机构的关系是律师与客户的关系，意味着机构是委托人。[263] 使情况更加复杂的是，一些法院区分不同类型的行动，认为总检察长在代表州实体处理某些类型的索赔时扮演传统律师的角色，而在其他情况下则不然；或者当总检察长以防御身份代表官员或实体时是这样，但当她代表州提起诉讼时则不是。[264]

所有这些复杂性使得公民很难将执法政策的责任归咎于特定人选，即使事实并非如此（即候选人试图传达清晰的执法信息，而媒体也在接收并向选民传播这些信息）。当多名官员共同承担（或看似共同承担）共同目标的责任时，他们在事情糟糕时有推卸责任的动机，在事情顺利时有争夺功劳的动机。党派冲突放大了这些动机。独立的总检察长选举创造了这样一种情景：来自一个政党的总检察长必须代表由对立政党州长控制的机构。[265] 即使是相对积极参与且知情的公民，要确定哪些民选官员对由此产生的执法政策负责，也可能是一项挑战（说得委婉些）。[266]

这些障碍不会消失。但是，各州不必放弃多元行政分支模式，就能改善执法背景下有意义问责的前景。总检察长自己可以做更多的事情来向公众通报他们的执法政策——不仅在选举期间，而且在整个任期内。例如，北卡罗来纳州总检察长（兼州长候选人）罗伊·库珀（Roy Cooper）

的网站将他的“首要任务”描述如下：

他的首要任务是打击犯罪和欺诈，并为人们提供正确的信息，以便他们就安全和资金做出明智的决定。 打击犯罪包括更严厉的法律，比如对制造冰毒的毒贩实施更严厉的惩罚。这意味着为调查人员提供更好的资源，比如更多地使用 DNA 证据。 保护消费者意味着打击欺骗人们达成不良交易（如高风险贷款或电话营销骗局）的诈骗艺术家。公共保护还意味着照顾该州最脆弱的居民，如长期护理机构的老年人和学校的儿童。[26 7]

库珀因提供任何关于其优先事项的信息而值得称赞；许多总检察长并未这样做。但库珀的清单表述得过于抽象，几乎没有提供关于他提议如何分配其办公室稀缺资源，或如何管理相互竞争的执法机会之间权衡的具体指导。

想要进一步了解库珀执法倡议的公民在他的网站上很难找到满意的答案。在“新闻和活动”标题下，库珀的网站包含一个指向“出版物和文件”的链接，结果是一个列出了 356 份文件的列表，没有明显的顺序，包括同意令、宣誓书、证物 and 起诉状。[26 8]

人民有权期望他们的律师做得更多。正如我们所见，关于公共政策的信息对于任何有意义的问责制度都是必不可少的。至少，此类信息对于有效的选举是必要的。但关于执法者以人民名义所做之事的透明度本身就很重要，不仅仅是“作为制裁代理人的前奏”。[26 9] 正如杰里米·沃尔德伦（Jeremy Waldron）所指出的，“在民主国家，人民的问责代理人有义务向人民说明他们一直在做什么，拒绝提供这种说明简直就是傲慢。”[27 0]

C. 公众参与

迄今为止的讨论一直集中在正式的问责机制上：通过选举直接监督执法，以及通过民选官员间接监督。然而，民主理论长期以来一直强调政府与被统治者之间进行额外、更非正式交流的机遇的重要性。[27 1] 这些非正式机制加强了选举和间接政治控制之间的联系，并填补了它们之间的空白。[27 2]

与这一观点一致，对问责制的担忧导致人们越来越强调公众参与机构的监管过程。[27 3] 公众参与的机会范围广泛，从请愿制定新规则，到参与规则制定（无论是通过协商规则制定、咨询委员会，还是通知和评论程序），再到在规则颁布后对其提出挑战。[27 4] 至少在理论上，公众参与为监管者生成有用的信息，促进对行政政策的公众审议，并

有助于确保监管回应不同利益相关者的需求。[275]

公众在执法中的作用要有限得多。一些机构被法规要求公布拟议的和解或同意令，并提供公众评论的机会。例如，《托尼法案》（Tunney Act）——是针对司法部与国际电话电报公司之间看似“私下交易”的广泛震惊而颁布的[276]——要求公布反垄断行动的拟议和解，并开放60天以促进公众评论。[277] 联邦《固体废物处置法》强制要求对环保署（EPA）为解决因不当处理固体或危险废物而对健康或环境造成的紧迫威胁而提起的案件的和解进行公众通知和评论。[278]《清洁空气法》下的某些执法行动也受到类似的关于和解的通知和评论要求的约束。[279]

虽然值得注意，但这些零散的与执法相关的通知和评论规定只是普遍规则的例外。绝大多数执法行动——无论是行政行动还是法庭内的民事行动——都没有此类公众参与的要求。而且，在没有法规规定要求公众访问的情况下，感兴趣的公众成员几乎没有机会了解，更不用说参与政府正在进行的执法努力了。许多执法行动只有在既成事实后才向公众披露：它们在向法院提交投诉或启动行政程序之前都是保密的，而到那时各方往往已经达成了和解。[280] 一些法规（特别是在环境领域）允许感兴趣的公民有权介入公共执法行动。[281] 然而，通常情况下，介入政府诉讼确实非常困难。[282]

即使适用通知和评论要求，它们也仅让公众参与实际在拟议和解中解决的问题。结果是，公众可以在塑造机构选择的道路上发挥作用，但没有任何机会对那些未选择的道路——即机构选择不进行的调查或法律论点——提供输入。[283] 由于调查和和解谈判的细节通常被屏蔽在公众视野和辩论之外，由此产生的披露省略了大量关于机构决策的信息。[284]

这一点揭示了现有公众参与规定的另一个问题：它们关注的是个别案件的解决，而不是一般执法政策的形成。一些机构——环保署再次作为一个例子——征求公众对年度执法优先事项的意见。[285] 由此产生的指南往往非常详尽且信息丰富。[286] 例如，环保署新的《清洁水法》行动计划是一份15页的文件，概述了《清洁水法》执法面临的挑战、环保署为征求各方利益相关者意见所采取的步骤，以及该机构未来改革执法的计划。[287]

其他机构发布详细的执法指南，但不寻求公众意见。[288] 例如，职业安全与健康管理局（OSHA）最近发布了一份新闻稿，宣布一项新

的“严重违规执法计划”（SVEP），解释说该计划“旨在将 OSHA 的执法资源集中在那些通过对法律规定的责任表现出冷漠而危及工人的顽固雇主身上”，并暗示该机构也正在制定改变其罚款政策的计划。[289] 该新闻稿包含一个指向 OSHA 网站的链接，其中包括对 SVEP 的详细描述，概述了新计划与该机构先前的强化执法计划有何不同，定义了“高重点危害”，并提供了严重违规执法案例的标准。[290]

正如这些例子所示，执法者完全有可能提供关于他们提议如何使用有限资源的具体信息，并让公众参与优先事项的设定过程。但这些例子 hardly 代表了整个执法领域。许多机构提供的关于其执法政策的信息很少，甚至根本没有，也没有说明这些政策与以往有何不同。即使是那些确实提供公共信息的机构也没有这样做的义务。正如理查德·穆尔根（Richard Mulgan）所论证的，“只有接收信息的人有权要求它……这种关系才是问责关系。纯粹自愿或恩赐式的透明度并不构成问责。”[291]

在此值得回顾的是，公众参与的益处是双向的。毕竟，通知和评论程序不仅向公众通告预期的政策变化，还邀请公众输入。信息交换的双方对于问责制都至关重要。然而，在执法背景下，我们往往两者皆无。

四、监管私人影响

问责制既有肯定的一面，也有否定的一面：说执法（或任何其他政府行动）应对公众负责，同时也意味着执法不应仅对或主要对狭隘的私人利益负责。上一部分侧重于肯定意义上的问责制，梳理了公众要求政府代表说明责任并追究其责任的机遇。正如我们所见，联邦层面的政治控制和州的选举创造了追究执法者决策责任的机会。但是，很大程度上由于缺乏关于执法的信息——即难以要求执法者说明责任——这些机制似乎并不十分有效。

本部分探讨我们目前对执法的处理中可能更为深层的问题，即涉及问责制的否定面。正式和非正式的公众参与及辩论机会的匮乏，并不意味着私人公民缺乏影响执法决定的能力。这意味着这种影响可能是不平衡且未公开的。第二部分讨论了几个使执法特别容易受到私人影响或俘获的特征。然而，尽管保护的必要性显而易见，但政策制定者为在其他背景下打击俘获而开发的工具，在大多数情况下并不适用于执法。[292]

首先，司法审查常被描述为防止监管俘获的关键机制。[293] 司法

审查迫使机构阐明其行动的公共利益理由；然后根据所提出的理由和相关法规体现的原则来检验法规。而且，“由于司法审查向所有受影响方开放，它可以作为政治和监管过程中有组织的特殊利益集团影响力的制衡。”[294]

当涉及执法时，司法审查受到了显著限制。当然，法院在决定诉讼案件的实质问题上发挥着重要作用，但绝大多数公共执法行动都以和解告终，往往甚至未进入法院。[295] 一些法院将执法和解视为完全不可审查；[296] 另一些则“只匆匆一瞥”。[297] 即使在法规要求法院确定机构和解是否符合公共利益的领域，[298] 审查也往往是草率的且明显具有 deferential（尊重性）。[299] 拒绝机构和解的决定——例如杰德·拉科夫（Jed Rakoff）法官 2011 年拒绝批准证券交易委员会（SEC）与花旗集团之间 2.85 亿美元和解的决定——之所以成为全国新闻，恰恰是因为它们如此罕见。[300]（拉科夫法官的决定后来在上诉中被推翻，被视为滥用自由裁量权。）[301]

法院也不会对政府执行或不执行的决定进行事后评判。在 Heckler v. Chaney 案中，最高法院认为，对执法决定的司法审查是不合适的，因为此类决定“通常涉及许多因素的复杂平衡，而这些因素特别属于[该机构]的专业知识范围”，包括“机构资源是最好花在此违规行为还是彼违规行为上”、“机构如果采取行动是否可能成功”、“所请求的特定执法行动是否最符合机构的整体政策”，以及“机构是否有足够的资源来开展该行动”。[302] 法院留下了在特定狭窄情况下进行审查的可能性——例如，当机构“‘有意识且明确地采纳了一项总体政策’，以至于构成了对其法定职责的放弃”。[303] 尽管如此，在 Heckler 案之后，对执法决定的司法审查已极为罕见。[304]

各种学者主张对执法决定（尤其是不执行的决定）进行更严格的司法审查。[305] 然而，很难想象法院会放弃 Heckler 案的立场，部分原因是执法决定不可避免地具有自由裁量性，部分原因是对不执行决定进行审查的后勤工作过于棘手。就当前目的而言，关键的一点是，法院不愿事后监管执法决定，这使得事前构建这些决定的做出过程变得尤为重要。本部分考虑了三种防止私人对执法产生不平衡影响风险的方法：透明度、选举改革和游说监管。

A. “阳光”下的执法

上一部分讨论了将透明度作为要求公共执法说明责任的手段，但

透明度也起着保护作用。其背后的直觉被那句著名的格言所捕捉：阳光是最好的消毒剂：[306] 透明度通过告知人民政府的事务来促进问责制，同时“限制机构俘获和自利交易的机会”。[307] 为了达到这些目的，联邦《政府阳光法》和《信息自由法》及其州级对应法案大体上要求政府工作在公众的充分视野下进行。会议必须向利益相关方和媒体开放；[308] 与官方政府事务相关的文件必须公开 accessible。[309]

“阳光”法规通常包含广泛的豁免，适用于与执法和诉讼相关的事项。[310] 原因不难理解：透明度可能会通过向对手或其他潜在违法者披露有关政府战略的敏感信息或政府案件的弱点，从而削弱执法的效力。[311] 类似的理由支持律师 - 客户特权，许多例外都是基于此。[312] 正如一家法院所解释的，“如果公众的‘知情权’强制允许听众 [参加有关和解和避免诉讼的讨论]，那么环座席位将被政府的对手占据，他们乐于利用每一个弱点的暴露。”[313]

虽然这些担忧有助于解释为何特定程序的信息公开被豁免于“阳光”要求之外，但它们并不能证明对更广泛的执法政策和优先事项保密是正当的。[314] 提高透明度的政治后果也不构成理由。在预算和人员有限的世界里，对执法优先事项的完整说明必然涉及讨论执法者未追求的问题。然而，此类公告可能在政治上具有风险。关于“保护消费者”的陈词滥调比详细解释执法者计划优先处理哪些类型的违规行为以及预计忽略哪些行为，给政治对手提供的弹药要少。也许这也有助于解释现状；但这并不能为其开脱。

反对透明度的一个更有力的论点是，暴露执法优先事项可能会通过降低制裁的感知可能性而鼓励违规。[315] 规避法律确实可能是透明度的代价，但问题不应被夸大。正如凯特·安德里亚斯（Kate Andrias）指出的那样，“老练的被监管方通常知道非正式、未公开的不执行或优先政策。”[316] 此外，在可能存在私人执法的领域，潜在违法者如果无视私人民事诉讼的可能性而依赖机构指南，那是愚蠢的。即使在没有私人执法的情况下，许多违规行为也要接受不同机构、不同州、或州与联邦政府的多层公共执法。[317] 这种“独特的美国式”执法方法[318] 往往反映了立法者有意识的努力，以避免将专属执法权置于单一行政机构手中——特别是在分裂政府时期。[319] 结果是，一个机构的不执行政策可能只能提供微弱的保证，即违规行为不会被追究。此外，罕见的情况是机构承诺绝不追究某一类违规行为，而不是为了其他违

规行为而淡化某些违规行为。[320]

在单一机构控制相关执法领域，且执法（或不执法）标准特别具体的领域，规避法律的风险可能更高。国税局（IRS）的审计程序就是一个例子。众所周知，国税局对其如何确定审计哪些纳税申报表守口如瓶，但现有证据表明，该机构使用了一个复杂且绝密的公式。[321] 披露该公式很可能通过提供避开国税局审查的详细蓝图而鼓励逃税。只要各州的审计程序不与国税局的完全一致，来自州税务当局审查的风险仍然存在。但为了论证起见，让我们假设国税局是唯一的游戏参与者。就当前目的而言，重要的一点是，威慑力的下降——即使是大幅度的——只是相关方程的一方面，必须与透明度和问责制的收益相平衡。虽然在某些情况下保密可能是最佳方法，但它不应成为不加思考的默认选项。至少应仔细权衡将执法政策保密的决定，而这些决定本身（及其理由）应尽可能透明。

B. 规制执法者选举

虽然普通公民很难了解执法政策，但有一部分公众往往非常清楚执法者在做什么：执法的目标和潜在目标。被监管实体有充分的动机试图影响执法，而总检察长（AG）选举——或者更准确地说，候选人资助其竞选活动的需要——带来了不平衡影响的特殊风险。改善关于执法的信息是打击这些风险的一种方法。另一种方法是更直接地关注如何规范执法者选举。

再考虑一下执法与裁决之间的共同点——特别是涉及离散的执法决定时。如果我们认真对待法院对司法选举的分析，我们就可以找到支持对执法者选举进行比立法者或其他行政职位更严格监管的依据。一种可能性可能是限制总检察长向即将或正在进行的执法行动（包括调查）的目标募集竞选捐款的能力。许多州限制司法候选人的个人募集，法院最近维持了此类限制，驳回了第一修正案的挑战。[322] 几个州还要求对司法候选人的捐款必须通过委员会渠道，而不是直接给候选人个人，并对候选人保密，以便法官不知道谁支持了他们，谁没有。[323] 至少在执法者选举的背景下，类似的保护措施非常值得考虑。或者，当选的总检察长可以自愿采取政策，不向执法目标募集或接受捐款，至少有一位已经这样做了。[324]

各州也可以考虑不在前端监管捐款，而是限制总检察长参与涉及大量竞选捐款人的案件。[325] 例如，一些州通过了法规，试图限制总检察

长与为州工作以换取费用（通常是回收金额的一定百分比）的私人律师之间的“权钱交易”安排。[326] 新闻报道揭示，赢得利润丰厚的州合同的律师往往碰巧是竞选支持者。[327] 作为回应，各州对外部律师的聘用实施了新要求，包括公开招标程序和限制或有费用。[328]

这些改革很重要，但它们无助于解决竞选捐款人是当事人或对方律师的案件相关的风险。在司法选举的背景下，几个州要求法官在涉及其财务支持者的案件中回避。在 Caperton v. Massey 案中，最高法院裁定，当相关捐款人在案件待决或即将发生时，通过筹集资金或指导法官的选举竞选，对将该法官安排在案件上具有“重大且不成比例的影响”时，出于正当程序的要求必须回避。[329] 法院强调，正当程序设定了回避的底线，各州可以通过法规采取更严格的要求。[330] 例如，在加利福尼亚州，如果在过去六年内或即将到来的选举中从一方或律师那里收到超过 1,500 美元捐款的法官，将被取消参与该案件的资格。[331] 纽约州禁止法官审理案件，如果涉及的律师或任何参与者在过去两年内捐赠了 2,500 美元或更多。[332]

执法者的回避规则看起来非常不同。在各州确实规范民事执法者回避的范围内，现有法规相对薄弱，且不区分民选执法者和职业公务员。[333] 州级的回避规则往往集中在政府律师之前的执业可能与当前案件发生冲突的情景上。[334] 没有任何州解决以竞选捐款等形式存在的同期影响的可能性。

C. 游说

最后，至关重要的是要关注游说在执法背景中的作用。游说法规通常要求游说者向政府注册，并定期提交其活动和支出的报告。一些州限制游说者进行竞选捐款的能力。[335] 此类法律的目标是促进公众了解影响公共政策的关键杠杆，并确保任何影响都是倡导的产物，而非更个人的诱惑。

联邦法律广泛定义“游说接触”，包括代表客户向“涵盖的行政分支官员或涵盖的立法分支官员”进行的任何沟通，内容涉及——除其他外——“联邦项目或政策的管理或执行”。[336] 但相关法规随后排除了“向机构官员进行的任何关于……司法程序或刑事或民事执法询问、调查或程序”的沟通。[337] 因此，试图影响一般执法政策的努力可能会被联邦游说法规覆盖，但试图影响特定执法行动的努力则不会。

州级的游说规则更为有限。有些仅适用于影响立法行动的努力。就其

管辖与行政行为者接触的范围而言，各州的规则 overwhelmingly 集中在影响行政规则制定的努力上。[338] 执法决定在大多数情况下被豁免。

结果是，在越来越多的资金流入总检察长竞选之际，[339] 与总检察长及其工作人员的接触几乎完全不受监管。《纽约时报》最近的一系列文章揭露了州一级游说的程度，描述了那些视自己为总检察长执法潜在目标的公司所做的精心努力。[340] 影响采取了多种形式，从向共和党和民主党总检察长协会（分别为 RAGA 和 DAGA）的大量企业捐款（这些协会反过来在独家静修会上购买接触总检察长的机会），到对个人总检察长选举和连任基金的直接竞选捐款，再到由游说者起草并由总检察长使用（有时逐字使用）的信函和法律文件。[341] 至少在有些案例中，这种影响似乎得到了回报。例如，《时报》报道说，密苏里州总检察长克里斯·科斯特（Chris Koster）指示其工作人员放弃对"5-Hour Energy"饮料的调查，此前他在加州一家海滩酒店举行的筹款活动上与该公司的一名律师（也是竞选捐款人）进行了交谈。[342] 在另一个案例中，科斯特办公室在与辉瑞公司（Pfizer）的消费者欺诈行动中结束和解谈判不久后，科斯特收到了在辉瑞政治行动委员会（PAC，另一家竞选捐款人）主办的活动上发表演讲的邀请。密苏里州与辉瑞的和解金额比其他提出类似索赔并单独和解的州少了 35 万美元。[343]

游说努力不仅针对执法；公司也试图说服总检察长发起特定的执法行动，往往针对其竞争对手。例如，拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands）的游说者（该集团于 2014 年向 RAGA 捐赠了 50 万美元）一直推动总检察长支持禁止在线扑克的努力。[344] 而且，总检察长和其他政府执法者与私人律师直接在执法倡议上合作正变得越来越普遍。如上所述，这些私人律师通常按或有费用工作，使他们在任何获胜中获得直接份额。[345]

《时报》的曝光引发了一阵改革浪潮，但迄今为止效果甚微。如果出于游说目的对执法的区别对待反映了立法者疏忽以外的其他因素，那似乎是基于政策倡导与直接客户代理或传统法律倡导之间的区别。我们不会称在行政法官面前代表客户的律师或与政府律师谈判和解的律师为游说者。我们只会称她为律师。这一复杂性表明，在制定执法背景下的游说法规时需要谨慎，但这并不能证明执法相关游说几乎完全缺乏监管是正当的。至少，游说规则可以涵盖非当事人及其律师试

图影响执法政策的努力。

结论

在关于民主政府问责制的大量文献的核心处，存在一个空白。现有的评论压倒性地关注于一方面是立法和监管，另一方面是裁决之间的对比。执法处于立法与法律适用的交汇点，这不仅体现在其运作方式上——将案件提交给裁决者，以便普遍适用的法律得以解释并适用于特定的个人和公司——也体现在其与那些更为熟悉的政府职能所共有的特征上。然而，执法在问责制文献中很大程度上被忽视了。

本文旨在填补这一空白。我已论证，公共执法是一种自由裁量性政策制定的形式，应被理解为一种政治代表形式。从这个角度看待执法有助于揭示问责制在执法背景下的重要性，同时也表明执法者可以“代表”公众，而无需盲从公众意愿。说公共执法应该问责，并不是要否认自主专业判断的必要性，而是要坚持政府有责任告知公民以其名义所做的事情，并反过来倾听他们的意见。呼吁问责也是呼吁建立机制，使公民可以尝试前瞻性地影响执法，或追溯性地“追究其责任”。而对公众的问责意味着需要一定程度的隔离，免受狭隘私人利益的影响。

我们目前对执法的处理远未达到这一愿景。在现行法律下，我们几乎没有工具来确保执法者政策决策的有意义政治问责——但我们也没有手段来保护执法免受不当影响。我们可以做得更好。

我已提出了各种改革途径，其中许多侧重于改善关于执法的可用信息。然而，此处的主要目标是诊断性的而非规定性的。作为初步尝试，我所提出的理论必然处于相对较高的抽象层面。要从理论转向具体改革，情境将是至关重要的。本文聚焦于民事/刑事分野的民事方面，但它探讨了许多司法管辖区的执法，包括各州以及联邦政府。不同的司法管辖区可能出于不同的原因，并在不同程度上依赖公共执法。因此，执法与公众意志之间的最佳关系在两级政府之间，或从一个州到另一个州，可能并不相同。例如，州总检察长作为“人民的律师”[34 6] 的角色可能表明，在州一级，天平应比在联邦政府中更倾向于回应性。或者，也许政策制定者可能会调整问责措施，以考虑执行相关法律的私人权利是否可用（或不可用）。我将这些问题留给未来的研究。然而，无论人们对公共执法的确切功能持何种观点，似乎清楚的是，现状远非最优。